

1500004-36.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os policiais militares Luiz da Silva Filho e Luiz Henrique de Lima, testemunhas de acusação, relataram em Juízo que estavam em patrulhamento e foram abordados por uma pessoa que lhes informou que, em frente ao mercado "Martins", quatro indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas. Os indivíduos avistaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500004-36.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500004-36.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000249/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22222702 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 4/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO

ITU, 2000249 - DEL.POL.SALTO, 4/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL MARTINS DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu LUCAS GABRIEL MARTINS DE CASTRO, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 21h57min, na Rua Campinas, nº 697, Jardim Cidade, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 51 (cinquenta e uma) porções de crack, com peso de 12 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 72-74).

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022 (fl.89-90). Durante a instrução

processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição com base em inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade, alternativamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação preliminar (fl. 10) e laudo de exame químico toxicológico (fls.87-88) bem como por toda prova oral coligida nos autos. A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os policiais militares Luiz da Silva Filho e Luiz Henrique de Lima, testemunhas de acusação, relataram em Juízo que estavam em patrulhamento e foram abordados por uma pessoa que lhes informou que, em frente ao mercado "Martins", quatro indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas. Os indivíduos avistaram a viatura e todos correram. As vestimentas repassadas pelo transeunte eram condizentes com aquelas dos indivíduos abordados. Após abordagem, na posse do réu localizaram várias porções, em torno de 53 ou 54, com substância análoga a crack.

O réu, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que estava vendendo a droga, há dois meses, a fim de sustentar o próprio vício. Afirma possuir uma dívida de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e praticava o crime para ter meio de pagar a dívida. Além da confissão do acusado, os policiais apresentaram versão firme e coerente demonstrando que o réu estava na companhia de outros três indivíduos e guardava e trazia consigo dezenas de porções de "crack" todas individualmente embaladas e prontas para entrega a consumo e fornecimento a terceiros. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Não restou provado que o réu fosse inimputável, o mero fato de o acusado ser usuário não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal. Além disso, não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade a considerar. Não há elementos mínimos nos autos que comprovem ter sido o crime praticado para que o réu se salvasse de perigo atual que não provocou (art. 24, §1º, do CP) ou coagido a praticar o tráfico de drogas. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do álibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o álibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para

praticar o delito. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relator: Guilherme de Souza Nucci.)

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 12 (doze) gramas de crack, os atos infracionais não são considerados como maus antecedentes ou reincidência, o réu é primário (fls. 104-105) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de policiais militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação do mencionado redutor. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

APELAÇÃO (recurso apenas defensivo) – Tráfico de entorpecente – Pleito da Justiça Gratuita atendido. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (§ 4º do art. 99 do NCPC), anotando-se, porém, na esteira do sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos" e que "a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das

Execuções", até porque pode sobrevir, naquele lustro, "mudança na situação econômica da beneficiária" - No mais, materialidade e autoria delitivas comprovadas - Sem olvido de que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do CPP) - , nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer equívoco, animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo. Seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. Ademais, existe, in casu, testemunha civil também a incriminar a ré - Em casos dessa ordem, onde a traficância imputada não é na modalidade "vender", em nada beneficia a acusada o fato de ela não ter sido avistada contatando outras pessoas e/ou vendendo-lhes o estupefaciente, nem mesmo a circunstância de nenhum tóxico ter sido encontrado em seu poder no momento da abordagem policial, eis que a increpação é de que ela "guardava" e "tinha em depósito" a droga, afigurando-se desnecessário saber, inclusive, de quem era a propriedade respectiva, posto que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo - Comprovada a narcotraficância irrogada, impossível a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Tráfico Privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006).

Cabimento. Como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar, ainda no momento dosimétrico (terceira etapa), a figura privilegiada (onde existe a mesma razão, aí há o mesmo direito: ubi eadem ratio ibi idem ius). (STF e STJ) - Indemonstradas circunstâncias outras a obstar a benesse legal, a aplicação de tal redutor legislado deve se dar no máximo legal (2/3), dado que o tóxico apreendido o foi em pequena quantidade (menos de 4 gramas de crack), com regime inicial aberto (diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, da primariedade e do quantitativo sancionatório), como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto (CP, art. 33, §2º, "c", e §3º, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III, e com o artigo 42 da Lei de Drogas) - Inconstitucionalidade do valor da pena de multa prevista na Lei Antidrogas - Inocorrência. A Lei nº 11.343/2006 é especial em relação ao Estatuto Repressivo (art. 49), de modo que, com rigores sancionatórios ínsitos à inafastável necessidade de se tutelar a saúde pública, deve prevalecer sobre a regra geral (lex specialis derogat legi generali), sem qualquer inconstitucionalidade, até porque editada pelo Poder Legislativo, a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir os tipos penais, mas também estabelecer as respectivas sanções. Toda e qualquer punição estatal advinda de condenação criminal repercute, de uma maneira ou de outra, no ius ambulandi do sentenciado, com inegável reverberação econômica não só à sua pessoa, como também àquelas que dele monetariamente dependam. Mas isso não pode significar, por óbvio, violação à intranscendência subjetiva das sanções, albergada no artigo 5º, XLV, da Constituição da República; as normas constitucionais não comportam interpretações estanques, devendo coexistir contextualmente, e, assim, também permitir a apenação daqueles que infringirem a normatividade penal posta, como se depreende de vários dos incisos hospedados naquele mesmo artigo 5º. Tem-se, nesse contexto, a busca do primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere), inclusive individualizando-se a pena, como expressamente contemplado no citado artigo 5º, desta feita no inciso XLVI, e dessa forma possibilitar o respeito à harmonia e ao bem-estar sociais, consoante o preâmbulo da mesma Lei das Leis - Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena corporal por duas restritiva de direitos, a teor da segunda parte do § 2º (quantum superior a 1 ano) do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Inviável tal permuta "por multa"; diversamente, se estaria desnaturando a mens legis, que cominou à espécie, cumulativamente, reprimenda prisional e (também) multa, de maneira que a aplicação de uma nova pena de multa não se afigura socialmente recomendável em casos que tais, pois, em última análise, ter-se-ia como resultado somente sanção pecuniária (STJ) - DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501447-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni;

Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analizada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presentes as atenuantes da menoridade e confissão, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUCAS GABRIEL MARTINS DE CASTRO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA